

1500037-26.2022.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desobediência

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500037-26.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-26.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desobediência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON LEANDRO MONTEIRO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de EDSON LEANDRO MONTEIRO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 afirmando que em 13 de janeiro de 2022, por volta de 18h, na rua Paiaguás, nº 1.035, Vila Sibila, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, descumpriu medidas protetivas de urgência em favor de sua irmã Andréia Cristina Monteiro, as quais foram deferidas nos autos nº 1501244-94.2021.8.26.0472, se dirigindo à residência da vítima e invadindo o imóvel.

Segundo a denúncia, "o denunciado é usuário de drogas e vinha demonstrando comportamento agressivo no local dos fatos, onde residia com a vítima, sua irmã, e o genitor. Em razão de ameaças ocorridas no dia 08 de novembro de 2021, a vítima pleiteou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos nº 1501244-94.2021.8.26.0472 - 1ª Vara, tendo o denunciado sido intimado pessoalmente no dia 09 de novembro de 2021 da ordem de afastamento, proibição de contato e aproximação dela (cf. cópia às fls. 98/101). Contudo, no dia 13 de janeiro de 2021, descumprindo as medidas protetivas de urgência determinadas, o denunciado se dirigiu à residência da vítima e invadiu o imóvel. Ao chegar no local, a vítima encontrou EDSON discutindo com o genitor, momento em o denunciado ameaçou agredi-la (crime de ameaça objeto de denúncia conjunta ofertada nos autos nº 1501245-79.2021.8.26.0472

- 1ª Vara). A Polícia Militar foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante por descumprimento da medida protetiva."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 24-A da lei 11.340/06 (lei Maria da Penha) assim descreve o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência:

Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

O tipo objetivo consiste na conduta de desobedecer, deixar de cumprir a decisão judicial que deferiu medidas protetivas contra o agente. Portanto, trata-se de crime próprio, sendo necessário que o autor tenha ciência da decisão judicial, ou seja, precisa ter sido intimado da decisão, bem como esta deve possuir validade. O objeto da conduta é a decisão judicial, sendo sujeito passivo o Estado.

O sujeito ativo é o agente que teve decretada contra si a medida protetiva de urgência, aquele que tinha o dever de cumpri-la e não o fez.

É crime formal e sua consumação se dá com o mero descumprimento de alguma imposição contida na medida protetiva deferida contra o agente, independentemente de resultado naturalístico ou a ocorrência de outra ofensa.

Já o tipo subjetivo é o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência baseada na lei 11.340/06. Não há crime se o agente agiu com culpa.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pela decisão que deferiu as medidas protetivas contra o acusado (fls. 98/101), pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 48/49) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A suposta vítima, Andréia Cristina Monteiro, na fase policial, disse que "é irmã de Edson Leandro Monteiro; que seu irmão é usuário de drogas e em razão do vício se tornou pessoa agressiva com os familiares e com a declarante; que, no final do ano passado, em razão de ameaças e pequenos furtos que EDSON cometia em casa, acabou fazendo boletim de ocorrência e requerendo medida protetiva nos termos da Lei Maria da Penha; que, embora Edson tenha saído de casa, em momento algum ele respeitou o distanciamento determinado pela justiça, uma vez que constantemente ia em sua casa, oportunidade em que fazia ameaças e provocava tumultos; que, na data de hoje, ao chegar em sua residência, EDSON estava no local, discutindo com seu genitor, o qual é pessoa idosa; que, ao ver a declarante no local, Edson passou fazer ameaças de agressão; que, diante disso, acionou a Polícia Civil que se fez presente no local e deteve seu irmão." Em juízo, manteve sua versão.

A testemunha de acusação, genitor acusado/vítima, Sebastião Silva Monteiro, na fase pré processual disse que Edson esteve no endereço citado na denúncia, na data citada na denúncia.

O policial civil Carlos Henrique Campos, na fase pré processual disse que "no final desta tarde, por volta de 18h00m, estava na Delegacia quando recebeu telefonema da vítima, ANDRÉIA CRISTINA MONTEIRO, informando que seu irmão, EDSON LEANDRO MONTEIRO, estava no interior de sua casa, sito no local dos fatos, em descumprimento de medida protetiva de urgência expedida nos autos do processo 1501244-94.2021.8.26.0472, da 1ª Vara Criminal de Porto Ferreira, que o proibiu de se aproximar dela ou de seus familiares, devendo manter distância mínima de 200 metros; que juntamente com o também policial civil Charles, foram até o local e, lá chegando, mantiveram contato com a vítima, a qual exibiu cópia da medida protetiva e acrescentou que o Indiciado havia adentrado na casa sem permissão e ainda

discutia com seu genitor; que ante esses fatos, estando o Indiciado naquele local, em flagrante descumprimento da medida citada, lhe foi dado voz de prisão e, após ser submetido a exame de corpo de delito, apresentado nesta Unidade para as medidas cabíveis; que durante o exame de corpo de delito foi realizado teste de COVID no indiciado que positivou." Não foi ouvido em juízo.

EDSON LEANDRO MONTEIRO, em declarações perante a autoridade policial, disse que "sobre os fatos deseja manifestar-se apenas em juízo." Em juízo disse que ser culpado.

Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, o depoimento da vítima, assim como o da testemunha, foi uniforme e coerente, amparado por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Com a devida vênia à defesa, não estão preenchidos os requisitos legais exigidos para o afastamento da imputabilidade do réu.

Configurado, assim, o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da lei 11.340/06), cujo preceito secundário prevê pena de "detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos".

Passo a dosar a pena.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que há inúmeros maus antecedentes contra o réu (0000088-75.2016.8.26.0552; 0004998-41.2009.8.26.0472; 0007558-53.2009.8.26.0472; 0008083-98.2010.8.26.0472; 0001432-69.2018.8.26.0472; 1500141-23.2019.8.26.0472), razão pela qual fixo a pena fixo a pena no máximo legal.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (0000568-31.2018.8.26.0472; 0000879-90.2016.8.26.0472). Conforme dispõe o art. 67 do Código Penal, a confissão só tem valor preponderante quando associada à personalidade do réu. No caso, a confissão foi feita sem qualquer demonstração de arrependimento resumindo-se à confirmação do já explicitado no flagrante, de modo que deveria prevalecer a reincidência com um aumento de 1/6 (um sexto). Todavia, tendo em vista a função constitucional dada ao STJ, principalmente na alínea "c" do inciso III do art. 105, e a consolidação do entendimento pela Terceira Seção, a qual reúne todos os ministros das turmas com competência criminal da corte, faço a compensação das circunstâncias e mantenho a pena no patamar indicado.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (0000568-31.2018.8.26.0472; 0000879-90.2016.8.26.0472). Prevalece a última implicando um aumento de 1/6 (um sexto). Deixo de aplicar o aumento em razão dos limites legais.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

A reincidência e a negativa das circunstâncias judiciais exigem o regime semiaberto; estas circunstâncias, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos não é adequada.

Inviável o benefício da substituição em razão da natureza do delito. É a orientação do enunciado 588 da Súmula do STJ:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR EDSON LEANDRO MONTEIRO à pena de detenção, pelo prazo de três anos, em regime inicial semiaberto, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Segundo o art. 112 da Lei 7.210/1984, a progressão de regime se dá com o cumprimento de 30% da pena (inciso IV - primário). No caso, tendo em vista que a prisão se deu em 13/01/2022, hoje 31/03/2022 completa-se 77 dias de cautelar, ou seja, pouco mais 7% da pena imposta, não havendo razões para alteração do regime inicial.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 31 de março de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA